

刑法
No151

予備独自問題 H28-12

(配点：2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 共謀共同正犯が成立するためには、実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令をすることが必要である。
2. 共謀共同正犯が成立するためには、実行行為を行わない者が実行行為の具体的内容の詳細を認識していることが必要である。
3. 共謀共同正犯が成立するためには、数人相互の間に、実行行為者の犯行の認識だけでなく、共同犯行の認識があることが必要である。
4. 順次共謀の形式では、共謀共同正犯は成立しない。
5. 共謀が明示的に行われなければ、共謀共同正犯は成立しない。

1 誤っている

最決昭57.7.16（百選I 77事件）。判例は、被告人が、タイ国からの大麻密輸入を計画したAからその実行担当者になって欲しい旨頼まれるや、大麻を入手したい欲求にかられ、自身が執行猶予中の身であったことから知人のBに対し事情を明かして協力を求め、同人を自己の身代りとしてAに引き合わせるとともに、密輸入した大麻の一部をもらい受ける約束のもとにその資金の一部（金20万円）をAに提供したという事案において、「大麻密輸入の謀議を遂げたと認めた原判断は、正当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、共謀はそれにより相手にどの程度強い心理的因果性を与えたかという点に加え、共謀者と実行者の関係、犯行動機、正犯者意思の明確度と強度、犯罪結果の帰属関係、実行行為以外の関与の内容などを考慮して認定されるものであり、本判例において、主従関係や支配関係がないにもかかわらず共謀共同正犯とされたのは、資金提供を行ったというにとどまらず、被告人自身が大麻を入手したいと考えて犯行の計画に積極的であったということを挙げている。よって、共謀共同正犯が成立するためには、実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令をすることは必ずしも必要ではない。

2 誤っている

最判昭43.3.21。判例は、「謀議が成立したというためには、単に他人が犯罪を行なうことを認識しているだけではならず、数人が互いに他の行為を利用して各自の犯意を実行する意思が存することを要するけれども、実行者の具体的行為の内容を逐一認識することを要」しないとしている。よって、共謀共同正犯が成立するためには、実行行為を行わない者が実行行為の具体的な内容の詳細を認識していることは必要でない。なお、その後に登場した判例（最決平19.11.14）は、被告人らが、自己の会社の借地に保管されていた廃棄物の処理を下請会社に依頼し、他の土地に捨てさせたという事案において、「不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの、不法投棄に及ぶ可能性を強く認識しながら、それでもやむを得ないと考えて」処理を委託したのであるから、「未必の故意による共謀共同正犯の責任を負う」と判示し、判例が、確定的故意を共謀共同正犯の要件としていないことが明らかにされた。

3 正しい

最判昭43.3.21。判例は、「共謀共同正犯が成立するためには、2人以上の者が、特定の犯罪を行なうため、共同意思の下に一体となって互いに他の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪の実行をしたことを要し……謀議が成立したというためには、単に他人が犯罪を行なうことを認識しているだけではならず、数人が互いに他の行為を利用して各自の犯意を実行する意思が存することを要する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、共謀共同正犯を認めるためには、客観的に、共謀に参加した者の誰かが実行に着手したことを前提に、実行行為を分担したと評価できるだけの謀議の存在と共謀者内での地位が認定されなければならない、ということを挙げている。よって、共謀共同正犯が成立するためには、数人相互の間に、実行行為者の犯行の認識だけでなく、共同犯行の認識があることが必要である。

4 誤っている

最大判昭33.5.28（百選Ⅰ75事件）。判例は、「数人の共謀共同正犯が成立するためには、その数人が同一場所に会し、かつその数人間に一個の共謀の成立することを必要とするものでなく、同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、次で乙と丙が共謀するというようにして、数人の間に順次共謀が行われた場合は、これらの者のすべての間に当該犯行の共謀が行われたと解する」としている。よって、順次共謀の形式でも、共謀共同正犯は成立し得る。

5 誤っている

最判昭23.11.30。判例は、「明示の意思の表示が無くても暗黙にでも意思の連絡があれば共謀があったといひ得る」としている。また、最決平15.5.1（百選Ⅰ76事件）は、暴力団組長たる被告人が、配下の組員らに対してけん銃等を携行して警護するように直接指示を下さなくても、組員らが自発的に被告人を警護するために本件けん銃等を所持していることを確定的に認識しながら、それを当然のこととして受け入れて認容していたものであり、そのことを組員らも承知していたという事案において、被告人と組員らとの間にけん銃等の所持につき黙示的に意思の連絡があったといえらる」としている。よって、共謀が黙示的に行われた場合にも、共謀共同正犯は成立し得る。